

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제05절 가구제>

[기출][2018-1-1]거부처분에 대한 행정심판 청구 시 임시처분의 요건 및 사안에의 인용가능성

《[문제1] 甲은 A국 국적으로 대한민국에서 취업하고자 관련법령에 따라 2009년 4월경 취업비자를 받아 대한민국에 입국하였고, 2010년 4월 체류기간이 만료되었다. 乙은 같은 A국 출신으로, 대한민국 국적 남성과 혼인하고 2015년 12월 귀화하였으나, 2016년 10월 협의이혼 하였다. 이후 甲은 2017년 7월 乙과 혼인신고를 하고, 2017년 8월 관할행정청인 X에게 대한민국 국민의 배우자(F-6-1)자격으로 체류자격 변경허가 신청을 하였다. 그러나 甲은 당시 7년여의 `불법체류`를 하고 있음이 적발되었고, 이는 관련법령 및 사무처리 지침(이하 `지침 등`이라 함)상 허가요건 중 하나인 `국내합법체류자`요건을 결여하게 되어 X는 2017년 8월 甲의 신청을 반려하는 처분을 하였다. 한편 甲과 乙은 최근 자녀를 출산하였다. 甲은 위 허가를 받지 못하면 당장 A국으로 출국하여야 하고, 자녀 양육에 어려움을 겪는 등 가정이 파탄될 위험이 생기므로 위 반려처분은 위법하다고 주장한다. (50점)

(물음1) 만일, 甲이 X의 반려처분에 불복하여 행정심판을 제기함과 동시에 임시처분을 신청하는 경우, 임시처분의 인용가능성에 관하여 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음1> 거부처분에 대한 행정심판 청구 시 임시처분의 요건 및 사안에의 인용가능성

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 대한민국 국민의 배우자 자격으로 체류자격 변경허가를 신청하였으나 X가 국내합법체류자 요건을 충족하지 못하였다는 이유로 반려처분을 하였고, 甲은 이에 불복하여 행정심판과 함께 임시처분을 신청하려는 상황이다. 쟁점으로 <행정심판법상 임시처분의 요건과 체류자격 변경허가 반려처분에 대한 임시처분의 인용 가능성>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲의 임시처분 신청이 행정심판법상 요건을 충족하여 인용될 수 있는지 논한다.

II. 행정심판법상 임시처분의 일반 법리

1. 임시처분의 의의 및 집행정지와의 보충성 관계

(1) 임시처분의 의의

- 임시처분은 "행정심판법 제31조"에 근거한 가구제 수단으로, 처분이나 부작위로 인하여 발생하는 중대한 손해를 예방하거나 급박한 위험을 막기 위하여 당사자에게 임시의 지위를 설정해 주는 적극적 효력의 예외적 구제 제도이다.

(2) 집행정지와의 보충성 관계

- "행정심판법 제31조 제2항"은 임시처분이 집행정지로 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 않는다고 규정하여 집행정지에 대한 보충성을 명시하고 있다. 따라서 소극적 가구제 수단인 집행정지가 가능한 영역에서는 임시처분을 청구할 수 없다.

2. 임시처분의 성립 요건

(1) 적극적 요건

- 임시처분이 인용되기 위해서는 ① 본안 심판청구가 적법하게 제기되어 계속 중이어야 한다. ② 처분이나 부작위가 위법·부당하다고 의심할 만한 상당한 이유가 있어야 한다. ③ 처분이나 부작위로 인하여 당사자가 중대한 손해를 입거나 급박한 위험에 처할 우려가 있어 임시의 지위를 정할 긴급한 필요성이 존재해야 한다.

(2) 소극적 요건

- ① 임시처분의 인용이 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없어야 한다. ② 본안 청구가 이유 없음이 명백한 경우에는 가구제의 필요성 자체가 조각되므로 인정되지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 집행정지에 대한 보충성 요건 충족 여부

(1) 거부처분과 집행정지의 한계

- X가 내린 반려행위는 신청을 거절하는 성격의 거부처분이다. 거부처분에 대하여 단순히 효력을 멈추는 집행정지 결정을 내리더라도, 처분 전의 상태인 무처분 상태로 소급할 뿐 행정청에게 가처분적 성격의 수리의무나 임시 허가 의무를 부과하는 적극적인 법적 효력은 발생하지 않는다.

(2) 임시처분의 허용성

- 따라서 거부처분은 집행정지 신청만으로는 신청인의 구제 목적을 실질적으로 달성할 수 없는 공백 영역에 해당한다. 이에 따라 "행정심판법 제31조 제2항"의 보충성 요건을 적법하게 충족하므로 임시처분의 신청 대상이 된다.

2. 긴급한 필요성 및 소극적 요건의 충족 여부

(1) 중대한 손해와 긴급한 필요성

- 甲은 체류자격 변경이 불허되는 경우 강제 출국을 당하여 귀화 후 이혼한 배우자 乙 및 최근 출산한 자녀와 즉시 격리되는 상황에 놓인다. 이는 신생아의 보호권과 가정을 유지할 헌법적 가치를 정면으로 위협하여 회복하기 어려운 중대한 손해와 급박한 위험에 해당하므로, 임시 체류 지위를 정해야 할 긴급한 필요성이 매우 명백하게 인정된다.

(2) 공공복리 영향 및 본안의 인용가능성

- 불법체류 경력이 존재하나 임시적인 체류 지위를 결정해 주는 것이 대한민국의 국가 안보나 공공복리에 직접적이고 중대한 위해를 끼친다고 보기 어렵다. 또한 본안 심판청구는 인도적 사정 및 아동의 복리라는 혼인과 가족생활 보장의 헌법적 가치를 간과하여 재량권을 일탈·남용한 실체법적 위법 사유가 상당하므로, 본안 청구가 이유 없음이 명백한 경우에도 해당하지 않는다.

IV. 결론

- 결론적으로 甲이 거부처분에 대하여 제기한 임시처분 신청은 법원에 의해 인용될 가능성이 매우 높다. 반려처분(거부처분)은 집행정지만으로 구제 수단을 강구할 수 없어 보충성 요건을 완벽히 갖추었으며, 본안 심판청구의 위법성이 소명되고 강제 퇴거 시 발생할 가족 결핍권 침해 및 영유아 양육 곤란의 긴급성이 충분히 인정되기 때문이다. 따라서 행정심판위원회는 甲에게 본안 심판의 재결이 내려지기 전까지 대한민국에 임시로 체류할 수 있는 지위를 보장하는 임시처분 인용 결정을 내려야 한다.